

1501637-18.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... passando necessidade e estava no tráfico porque precisava de dinheiro. Não presenciou a abordagem do outro indivíduo, mas se recorda que com ele havia anotações relativas ao tráfico e quantia em dinheiro. Robson negou envolvimento com o tráfico na ocasião. Não havia outras pessoas no local. Não conhecia os réus antes da abordagem.

No mesmo sentido, a testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501637-18.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501637-18.2021.8.26.0537 2021/001388

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERNANDES DAS NEVES e outro

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

ROBSON ALVES DE LIMA, qualificado à fl. 19, e LEONARDO FERNANDES DAS NEVES, qualificado à fl. 20, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 00h36, na Rua Serra do Tumucumaque, altura do nº 23, Campanário, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 78 porções de "crack", com peso de 27,17g., 38 porções de cocaína, pesando 19,46g., e 53 porções de maconha, com peso de 128,5g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo o flagrante dos réus em prisões preventivas (fls. 66/69).

Notificados (fls. 108 e 109), os réus apresentaram defesa prévia às fls. 118/121 e

a denúncia foi recebida em 19/10/2021. No ato, deferiu-se a liberdade ao réu Robson (fls. 123/124).

O réu Robson não foi encontrado no endereço que informou por ocasião do cumprimento do alvará de soltura (fls. 140/143 e 180). O réu Leonardo, por sua vez, foi citado pessoalmente (fl. 186).

Nesta data, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas policiais, interrogado o réu Leonardo e prosseguiu-se com a gravação dos debates orais entre acusação e defesa. No ato, reconheceu-se a revelia do réu Robson, que não foi encontrado no endereço informado nos autos. Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia, sob o argumento de que autoria e materialidade foram bem demonstradas nos autos. No tocante à dosimetria, requereu o aumento da pena base em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes; o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência em relação ao réu Leonardo. Alegou, ainda, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade em relação ao réu Leonardo e a decretação da prisão preventiva do réu Robson, que é revel.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, sob com fundamento na fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que somente foi produzida prova policial, mas esta não seria suficiente a condenação, já que os entorpecentes não teriam sido localizados em poder dos réus, não se podendo confirmar com certeza que pertencia a eles. Não foi realizada campana, nenhum usuário foi visto adquirindo entorpecentes, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no piso legal, já que Robson é primário e sem Maus antecedentes e porque a quantidade de drogas apreendidas não difere da média da comarca. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da agravante da confissão espontânea para o réu, tendo em vista que admitiu que estava com a sacola. Na derradeira etapa, requereu a aplicação da figura do privilégio, aplicando-se regime diversos do fechado, descontando-se da pena total o tempo que os réus permaneceram presos, para fixação de regime mais brando, deferindo-se a eles o direito de recorrer em liberdade, indeferindo-se o pedido de prisão preventiva do réu Robson, formulado pelo Ministério Público.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 06/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), do laudo de constatação (fls. 44/46), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 115/117), do comprovante de depósito (fl. 114), dos laudos periciais dos objetos (anotações e sacola - fls. 193/198 e 199/200) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

O réu ROBSON não foi encontrado no endereço informado nos autos, tornando-se revel, razão por que não foi ouvido em juízo.

O réu LEONARDO, em seu interrogatório judicial, afirmou que são verdadeiros em parte os fatos narrados na denúncia. Disse que havia cerca de mais dez pessoas no local dos fatos, mas que havia passado ali somente para pegar maconha. Não conhecia Robson e somente sabe o nome dele porque estava nos seus papeis. Robson o chamou e pediu para que segurasse a sacola, pois precisava chamar alguém para ficar de vigia. Tinha conhecimento do local, pois frequentava um bar ali perto; então segurou a sacola nas mãos e ficou no local em que Robson lhe serviu a droga, momento em que ele andou cerca de dois metros e já gritou que a polícia estava vindo, quando então todos correram, largou a sacola, mas esta foi recuperada cerca de um metro de distância de si. Envergonha-se, mas admite que os fatos foram estes. Os demais elementos de prova trazidos aos autos, contudo, foram suficientes para comprovar a prática do crime pelos dois réus.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado em sede judicial, a testemunha Leonardo Alexander Lyra, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pela avenida, quando olhou na travessa e avistou os dois réus, Leonardo segurando uma sacola em suas mãos. Como ali é ponto de venda de entorpecentes, solicitou apoio e ficou na saída da viela. A viatura adentrou e o réu Leonardo correu em sua direção, realizando a sua abordagem, ocasião em que portava uma sacola com entorpecentes. Não se recorda da quantidade, mas se lembra que era diversos entorpecentes. O réu disse que estava passando necessidade e estava no tráfico porque precisava de dinheiro. Não presenciou a abordagem do outro indivíduo, mas se recorda que com ele havia anotações relativas ao tráfico e quantia em dinheiro. Robson negou envolvimento com o tráfico na ocasião. Não havia outras pessoas no local. Não conhecia os réus antes da abordagem.

No mesmo sentido, a testemunha Carlos Henrique Coletti Costa, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que estava em patrulhamento e visualizou na travessa, que é conhecida como ponto de venda de drogas, uma movimentação estranha. Pediu apoio a outra viatura para realizar o cerco, desceu com a viatura até a rua debaixo e deixou seu parceiro na rua de cima. Quando desceram, o réu Robson começou a gritar "moiô, moiô" e saiu correndo, mas conseguiu aborda-lo, enquanto o outro réu, Leandro, saiu correndo pelo outro lado da viela e foi abordado por seu companheiro de equipe. O depoente realizou a busca pessoal em Robson e localizou com ele anotações e aproximadamente R\$ 85,00, em dinheiro. Nesse momento, seu colega de equipe chegou com Leandro e disse que ele já tinha confessado a prática do tráfico. A contabilidade a que se referiu seria anotações típicas de tráfico. Os réus confessaram para a equipe que estavam na prática do tráfico. Não conhecia os réus antes dos fatos. Havia apenas os dois réus no local da abordagem.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor dos réus, pois é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder dos réus (78 porções de "crack", com peso de 27,17g., 38 porções de cocaína, pesando 19,46g., e 53 porções de maconha, com peso de 128,5g.), e as circunstâncias em que ocorreu as prisões (policiais estavam em patrulhamento de rotina quando notaram dois indivíduos com comportamento suspeito, acionaram reforço e resolveram realizar a abordagem e os réus empreenderam fuga quando perceberam a aproximação policial, tendo LEONARDO dispensado uma sacola no chão. Contudo, foram capturados, revistados e, na sacola que estava em poder de Leonardo, os policiais encontraram as porções de entorpecentes acima indicadas. Já com ROBSON, os policiais encontraram a quantia de R\$ 85,65 e anotações típicas de tráfico), tendo Leonardo confirmado que estava em poder da sacola que continha os entorpecentes, no momento da chegada dos policiais, evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia aos dois réus e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes por ambos, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar que a condição de viciado do réu Leonardo não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a

prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder de cada um dos réus é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal. Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que sejam condenados os réus nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao réu ROBSON:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que ROBSON não ostenta Maus antecedentes (fl. 51). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Observo, ainda, que o número de porções apreendidas com o réu não é expressivo o suficiente para destoar da média das apreensões que costumeiramente ocorrem nesta Comarca, sendo desproporcional aumento da pena por tal motivo. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu primário e não há outras atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase, reconheço a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista pelo § 4º do artigo da Lei nº 11.343/06, já que o réu é primário e sem antecedentes e, apesar de ter sido surpreendido em poder de anotações típicas de traficância, praticando a conduta em concurso de agentes, não há demonstração segura de que se dedicasse a atividades criminosas de forma habitual ou de que integrasse organização criminosa. Note-se que o réu contava com apenas 32 anos ao tempo dos fatos (fl. 19) e que ele não conta com nenhuma passagem criminal anterior (fl. 51). Ademais, os entorpecentes foram todos encontrados em poder de Leonardo. Em face de tais motivos, reduzo a pena na proporção máxima, de 2/3, alcançando, assim, o montante de pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, que torno definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, uma vez que este se revela suficiente à prevenção e repressão do crime. Ressalto, aliás, a tendência de nossos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico em sua forma privilegiada (§ 4º do artigo 33) não é considerado como hediondo e, bem por isso, se as demais circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de fixação de regime rigoroso, possível a fixação de regime mais brando.

Inviável, entretanto, a substituição da pena, uma vez que insuficiente a repressão e prevenção do crime, já que houve a apreensão de anotações e de quantia em dinheiro, que evidenciou que o réu já havia contribuído para a disseminação de porções a usuários de entorpecentes. Logo, a substituição da pena não seria socialmente recomendável.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até o cumprimento de seu alvará de soltura, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, sendo certo, ainda, que ao réu Robson está sendo fixado o regime mais brando possível, ou seja, o regime aberto.

Dosimetria do réu LEONARDO:

Tendo em conta as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes. No mais, a culpabilidade é normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, o qual estabeleço à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu. Observo, ainda, que o número de porções apreendidas com o réu não é

expressivo o suficiente para destoar da média das apreensões que costumeiramente ocorrem nesta Comarca, sendo desproporcional aumento da pena por tal motivo. Na segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, específica pelo tráfico de drogas (autos nº 0001705-81.2017.8.26.0537 - com trânsito em julgado para a Defesa em 08/02/2018 e extinção da pena em abril de 2020 - fls. 54/55). Anoto, neste ponto, que não é possível a aplicação da figura da atenuante da confissão espontânea, pois o réu Leonardo, apesar de ter admitido que estava com a sacola de drogas em suas mãos no momento da chegada dos policiais, NEGOU que estivesse em poder da mesma com a finalidade do tráfico, aduzindo que segurava a sacola rapidamente, fazendo um favor ao verdadeiro traficante. Assim, não houve confissão da prática delitiva, mas tão-somente versão defensiva que procurava isentar o réu Leonardo de responsabilidade. Assim, majoro a reprimenda na proporção de 1/6, chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente, específico na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício. A propósito:

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente, e, especialmente, em razão da quantidade e variedade de drogas, circunstâncias preponderantes à teor do art. 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO LEONARDO FERNANDES DAS NEVES à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, e, ainda, ROBSON ALVES DE LIMA à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No mais, INDEFIRO ao réu LEONARDO o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório, a gravidade concreta da conduta e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena. Note-se que o réu é reincidente específico e já cumpriu pena, mas tal medida não foi suficiente a impedir que ele tornasse a delinquir, de maneira que a manutenção de sua prisão é necessária como garantia da ordem pública.

Havendo recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória de Leonardo e, nada sendo requerido, expeça-se a definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas e anotações de estilo.

Já em relação ao réu ROBSON, a despeito da gravidade concreta da conduta, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois, como bem salientado pela D. Defesa, não há comprovação no sentido de que ele tenha se mudado do endereço informado, sem avisar ao Juízo, já que o imóvel não foi localizado pelo Oficial de Justiça, o que se deu em razão da precária ocupação do logradouro onde reside.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva de Robson. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos dois réus, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista que tiveram seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à

realização do laudo definitivo.

Tratando-se de bens sem valor comercial, autorizo a destruição da sacola e das anotações em papel apreendidas.

Com relação ao valor apreendido (R\$ 85,65 - fl. 114), tratando-se de produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União. Proceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA